民诉-2026

- ## A.总论
- **一、基本理论、原则和制度**
  - 1、本质
    - 平等主体对抗，法院居中解决纠纷
    - 中国境内只适用民诉法，实体法可选择其他；民诉法无溯及力，刑法可能有
  - 2、诉讼程序 VS 非讼程序
    - 诉讼程序：解决民事权利义务纠纷（一审、二审、再审）
    - 非讼程序：不解决民事权利义务纠纷（特别程序除选民资格、督促程序、公示催告程序）
    - 选民资格不属于诉讼程序 / 非讼程序
  - 3、诉的要素
    - 主体：当事人
    - 法律理由
    - 标的：实体法律关系，不是诉讼请求
      - 区分标的物、标的额
      - 诉讼标的（性质）选择有重要影响
  - 4、诉的分类
    - **分类（前提是诉+有诉的利益）**
      - 确认之诉：积极（确认法律关系存在）、消极（仅有存在诉的利益时能够提确认诉）
        - 仅能确认法律关系、且有诉的利益，不能仅确认一个事实
      - 给付之诉：财物、行为
      - 变更之诉：消灭或变更既存法律关系（同民法的形成之诉）
        - 诉的分类不适用非诉案件
    - 确认之诉 VS 形成之诉
      - 确认之诉：法律关系是否有效待定
      - 变更之诉：法律关系一定有效
      - eg. 起诉解除合同，注意诉的性质依情况可能有区别。若合同约定解除事由已满足、通知解除后起诉，诉为确认合同关系自始不存在
        - 若仅因为情势变更请求解除，则为变更之诉，解除时不存在
  - 5、反诉
    - 概念：独立性
    - 构成

        - 主体：同一性，被告告原告
        - 牵连关系
        - 时间：一审辩论终结前
            - 二审反诉
                - 调解
                - 另行起诉
                    - 双方同意，可以一并裁判
- **6、基本原则**
    - **（1）辩论原则（控制证据与事实）**
        - 诉讼程序的任何问题（当事人）可以辩论
        - 其他程序（不解决纠纷的如执行程序）不能辩论
        - 辩论内容对法院有约束力
            - 没提的主张不允许裁判，没提的证据不允许调取
    - **（2）处分原则（控制标的与请求）**
        - 处分必须在法律规定的范围内，法院不能超出原告诉请范围判决
        - 放弃不得损害国社他利益否则无效
            - eg. 重婚起诉解除第二段婚姻后要求撤诉，法院不允许撤诉
    - **（3）诚实信用原则**
        - 多方串通、单方捏造虚假诉讼、恶意诉讼：判决驳回诉讼请求，不是裁定驳回起诉
    - **（4）检查监督原则（检察院）**
        - 范围：审判权、执行权
        - 方式：抗诉、检察建议
    - **（5）自愿、合法调解原则**
        - 不允许调解
            - 身份关系的确认诉等性质上不宜调解的案件方一致同意才可调解
            - 非诉程序不允许调解
    - **（6）同等、对等原则**
        - 外国人、无国籍人、外国企业和组织不受欺负
- **7、基本制度**
    - **（1）回避制度**
        - 对象
            - 中立方：**审书助执勘技翻鉴**
                - 审判人员、书记员、法官助理、执行人员、勘验人、司法技术人员（公务员）、翻译、鉴定人（社会机构）
            - **证人不回避：不可替代**

- 原因：
  - 关系回避：近亲属（两圈）
    - 同案多角冲突仅允许担任一个角色
  - 行为回避：经济利益关系、违规会见（非工作时间+工作地点）
- 回避方式：自行、申请、指令
  - 申请：当事人、代理人的近亲属，法庭辩论终结前申请
- 找谁决定
  - 院长担任审判长回避：审判委员会决定
  - 审判人员回避：院长决定（含人民陪审员，28周岁、高中以上文化）
  - 其他人员回避：审判长决定
- 申请效力：3日内决定，暂停本案工作，要采取紧急措施除外
  - 中途回避，不返工
  - 回避用决定，可申请一次复议，复议期不停止工作
- **（2）公开审判制度**
  - 例外不公开
    - 法定：国家秘密、个人隐私
    - 申请：离婚诉讼、商业秘密
      - 民诉99%都是单方申请
  - 评议、宣判
    - 评议：一律不公开
    - 宣判：一律公开
- 合议制
  - 合议庭
    - 一审：审判员、人民陪审员或审判员
    - 二审：审判员
    - 再审
      - 原一审：按一审程序，不适用简易程序
      - 原二审或上级提审：按二审程序
    - 特别程序
      - 选民资格案件、重大疑难案件：审判员
    - 人民陪审员：适用一审程序的诉讼程序
  - 独任制
    - 简易程序：基层法院审理简单的一审
    - 特别程序：除选民资格案件、重大疑难案件
    - 督促程序：支付令

        - 公示催告程序：除宣告票据无效
    - 两审终审制度
- **二、当事人**
    - 1、诉讼权利能力：始于出生终于死亡
        - 自然人、法人、其他组织
        - 纯获利胎儿
    - 2、诉讼行为能力：亲自参加诉讼行使诉讼权利
        - 法人和其他组织
        - 自然人
            - 完全民事行为能力人有诉讼行为能力
            - 无、限制民事行为能力人无诉讼行为能力
    - 3、当事人适格：有起诉、应诉资格
        - 原则：争议关系的主体
        - 例外
            - 确认之诉中，对诉讼标的有确认利益
            - 根据当事人意思或法律规定，对他人享有管理权
            - 根据法律规定，有权提起公益诉讼的机关、组织
    - 4、常考的
        - 个体工商户告谁：
            - 有字号的告字号，没字号的告经营者（登记的、实际的）
        - 合伙告谁：
            - 有无执照，没执照是个人合伙
        - 提供劳务告谁：
            - 雇员侵权告雇主，劳务派遣有过错的一起告，知道派遣方过错份额的可单诉
            - 不发工资的，仲裁前置，派遣单位和用工单位连带责任
        - 清算注销企业怎么告：
            - 告公司，清算前法代出庭，清算中清算组负责人/破产管理人出庭，清算结束谁都不能告了
            - 没走正常清算就注销了，告股东、老板
        - 村民委员会 / 村民小组
            - 村民委员会
            - 有独立财产的村民小组
        - 死者
            - 近亲属
    - 5、共同诉讼

- 一方当事人大于等于2
- **必要共同诉讼**
  - 特征：一个诉讼标的（夫妻买房），一起参加诉讼（没来要追加），法院必须合并审理，最后一个判决
  - **常考的**
    - 遗产继承，不愿参加诉讼又不明确放弃实体权利，列为共同原告
    - 追索赡养费，所有赡养义务人作为共同被告
    - 无、限制民事行为能力人，与监护人为共同被告
    - 共同财产被侵权：夫妻车被砸坏，共同原告
    - 一般保证：只诉债务人，或债务人、保证人一起诉没问题（执行分先后）
    - 不用追加的共同诉讼：连带责任
      - 连带保证
      - 共同危险或共同侵权
      - 挂靠和借用
  - 追加当事人：辩论终结前申请、法院依职权
    - 放弃实体权利可不追加共同原告，不放弃要追价
    - 法院追加共同被告不需要征得被告同意。
- **普通共同诉讼**
  - 特征：多个诉讼标的，部分合并或分别诉讼，彼此独立，最后多个判决

- **6、诉的合并**
  - 立法不存在，理论中存在
  - 主体合并：共同诉讼
  - **客体合并：原告被告各1个，但中间有很多标的**
    - 单纯合并：比如离婚中的财产、子女抚养归属，可合并也可分开诉
    - 竞合合并：多个诉讼标的，比如可乐瓶爆炸，侵权责任和违约责任只能择一
    - 选择合并：1个诉讼标的多个请求且无先后，比如车搞坏了，要求维修汽车或赔给维修费
    - 预备合并：2个请求但有先后顺序，比如要求解除合同，如不能解除要求继续履行
  - 有牵连关系一个判决，没有多个
- **7、诉讼代表人制度**
  - 人数众多：10 人以上
  - 推举代表：2-5 人
  - 共同诉讼，对所有人均发生效力
    - **承认、放弃、变更诉讼请求+和解（属于往后退）须经所有人全部同意**
  - 分类

- 人数确定的代表诉
  - 形式：必要共同诉讼或普通共同诉讼
  - 代表全体选或部分推选，选不出来的自己上
- 人数不确定的
  - 形式：只能是普通共同诉讼
  - 代表：全体或部分推选，选不出法院可指定，还不行的只能自己上
  - 效力：
    - 对登记人有**约束力**
    - 对另诉人有**预决效力**

- 8、第三人
  - **有独三**
    - 本诉：甲诉乙
    - 参加之诉：张三诉甲乙，**既反对本诉原告，又反对本诉被告（具有优先性）**
      - ex. 甲把张三的房偷偷卖给乙、乙不给钱，张三觉得甲卖得很好决定分钱，于是与甲一起起诉乙要房款，这时是必要共同诉讼
      - ex. 张三发现后不同意甲卖、不同意乙买，有独三
      - **有独三是本案的当事人，不是本诉的当事人，是参加之诉的当事人**
    - **独立性：不因本诉撤销而撤销，但不能提管辖权异议（可以另院另诉）**
    - 参加方式：主动起诉，法院不能追加
    - 参加时间：本诉受理后、辩论终结前
      - 参加二审，法院调解
      - 调解不成，撤销原判，发回重审（如果告知定诉，可能冲突判决）
  - **无独三**
    - 本诉：甲诉乙
    - 辅助：张三，与乙有**法律上的利害关系**（非事实上的利害关系，如还了丙钱就没钱还丁）
      - **与共同被告的区别在于张三与甲没有法律关系**
    - ex. 张三是河豚厂家，乙是日料店，甲是食客
      - 如果甲基于违约告乙，那么只能把张三添加为无独三，承担**补充责任**
      - 如果甲基于侵权可告张三和乙，共同被告，**连带责任**
    - 参加方式：法院追加或自己申请
    - 地位权利：
      - **对判决责任有权上诉，调解义务得同意，可承认诉讼请求**
      - **不能提管辖权异议，不能放弃、变更诉讼请求、撤诉**
- 9、当事人的更换与无独三

- 原则：没办法才能换
- **考试中才能换的：法人的分立、合并、终止，自然人的死亡**
- ex. 甲先起诉乙，乙将权力义务转给张三，如果乙不属于合并、分立、终止、死亡情形则不能更换
  - **如果法官同意换人，就换人把程序从头来一遍，如果不同意则可列张三为无独三**

- 10、诉讼代理人
  - 法定代理人：未成年人和精神病的监护人，无需授权
    - 全权代理，以当事人名义
  - 委托代理人
    - 代理权限
      - 特别授权：**承**认、放弃、变更诉讼请求，**和**解、**反**诉、**上**诉
      - 一般授权：除了特别授权外的程序性权利（不能撤诉），仅写明「全权代理」视为一般授权
    - 法律效果
      - 原则：当事人可以不出庭，例外是离婚
    - 外国人要找中国律师（域外过来的授权书要公证或在法官见证下签授权书），可以找普通公民
  - 第三人是当事人、代理人不是当事人

- **三、管辖**
  - 1、两审
  - 2、四级
    - 基院
      - **北京、广州、杭州设有互联网法院，管互联网上的案件，网上开庭**
      - **网络产品、借款、著作、侵权案，改归普通基院管**
    - 中院
      - 重大涉外、重大影响、涉及仲裁
      - **最高院指定的中院管辖（海港专公）**
        - **海**事海商
        - 重大涉**港**澳台
        - **专利纠纷：北上广知产庭+其他指定的部分中院（和基院）**
        - **公**益诉讼
    - 高院
      - 全省范围重大影响
    - 最高人民法院
      - 全国范围重大影响

        - **认为应当由本院审理（仅最高院有权）**
- 3、一般地域管辖
    - **一般原则：原告就被告**
        - 公民当被告：住所地或经居地（**离开住所满1年，连续居住到诉前**，除了医院，可以为监狱）
        - 法人当被告：注册地或主要办事机构所在地
    - **强监黑户找不到，此时被告就原告：原告住所地**
        - 强制教育（收容教育、收容教养、强制戒毒），监禁（坐牢），户籍被注销人还活着（比如宣告死亡），宣告失踪了、移民了（仅限于身份诉讼，比如要赡养费、离婚）
        - 原被告都进去了、户籍都被注销了，那就还是就被告吧，1年以上关起来的地方是经居地
    - **被告异地抚扶赡，离家1年离婚案，原被告地都可管**
        - 离家的那个起诉在家的、或两方都离开的，就被告
- **4、专属地域管辖**
    - **不动产纠纷：不动产登记地**
        - 不动产（土地、房屋、山林等）确权、分割、相邻关系**3类**
        - 及土地承包经营、建设工程施工、房屋租赁、政策房买卖**4种合同纠纷**
            - 装修动到主体结构的属于建设工程施工，否则是承揽
    - **港口作业纠纷：**港口所在地法院管
    - **遗产继承：死人死时住所地、价值最大的遗产所在地**
    - **涉外的三种（没管到不承认、不执行）**
        - **三合国家扯皮**：中外合资、合作经营、合作勘探开发自然资源
        - 法人或其他组织**设立、解散、清算及决议**效力有关纠纷
            - 其章程、名册等核心证据、经营地和财产存放境内有利于查明
        - 知识产权有效性
    - **涉军：军事法院（1方可能管，2方必管）**
- 5、协议地域管辖
    - **一审、财产、书面、不违背专属和级别**
        - **人身案件不可以（夫妻离婚中的财产部分可以协议）**
        - 协议约定履行地发生变化的，以协议达成时的为准
    - 格式条款要提醒注意
    - 可以选哪些：原被告住所地、合同签订地、合同履行地、标的物地
        - 涉外案，多一个侵权行为地
        - 协议后住所地变更的，无其他约定依原址
        - 买卖合同是主合同，协议管辖合同是从合同，协议管辖对于主合同受让人也是有效的

- 6、特殊地域管辖
  - **合同履行地：有约从约，没有得看被告住所地（经居地优先住所地）+合同履行地**
    - 即时交货：奶茶店
    - 给付货币：收钱地
    - 不动产买卖、租赁：所在地、使用地
    - 网购：虚拟购物买方住所地，包裹购物收货地
    - **其他合同：履行义务方所在地**
      - ex. 张三找甲买东西，张三起诉甲不发货，被告住所地和履行义务方（被告）所在地，都是甲住所地
      - ex. 张三找甲买东西，张三不给钱，被告住所地和收钱地，即张三住所地和甲收钱地
    - **若合同有约定+未实际履行+约定又不在双方住所地，则只能由被告住所地管（不方便）**
  - **侵权纠纷：**
    - 被告住所地，侵权行为地（实施地+结果地）
  - **产品质量侵权（侵权特别法）**
    - 被告住所地，侵权行为地（实施地+结果地）、**产品制造地、销售地**
  - **服务质量侵权（侵权特别法）**
    - 被告住所地，侵权行为地（实施地+结果地）、**服务提供地**
  - **运输合同纠纷**
    - 被告住所地，**运输始发地、目的地**
  - **交通事故损害赔偿纠纷**
    - 被告住所地，**事故发生地、最先到达 / 降落地**
  - **海难救助 / 共同海损：**
    - **海事法院管，无被告住所地**
  - **公司诉讼：（公司治理有关的，不是侵权）**
    - **公司住所地**
  - 保险纠纷：被告住所地，保险标的所在地
  - 票据纠纷：被告住所地，票据支付地
- **7、地域管辖判断顺序**
  - **专属管辖4——协议管辖——特殊地域管辖——一般地域管辖**
- 8、选择管辖与牵连管辖
  - 多管可任选，多选先立管，先立后不立，后立送先立
  - 财产涉外案件，只要和中国有所牵连就可以管
- 9、裁定管辖

- 移送管辖：错误立案的纠错程序，法院移送到认为正确的法院
  - 无需同意、只能移送一次
  - 觉得移错了报请上级定，可以就继续审，不行就指定管辖出去
  - 共同管辖，后立案移送先立案
- 管辖权转移（从有管辖的到没有管辖的）
  - 下级转上级
    - 上调：上级认为应由自己管辖
    - 上报：下级认为需要上级管辖，经同意
  - 上级转下级
    - 下放：上级认为确有必要交给下级，报请自己的上级批准
      - ex. 破产案、环境污染、当事人众多，但可能降低审判质量
- 指定管辖
  - 管辖有障碍：由于特殊原因（全体回避、自然灾害）不能行使管辖权
  - 管辖权争议：都想审、都不想审，协商不成，报共同上级法院
- **怎么做题：俩法院没争议就报自己上级，有争议就共同上级**

- **10、管辖权异议**
  - 时间：仅一审答辩期内，当事人提，有独三、无独三不能提出
    - **提交了答辩状视同认可了管辖，如果案件根据级别和专属管辖其实管辖错误，便只能靠法院移送，没移送的继续审完**
  - 法院15日内对异议进行审查，成立的移送管辖，不成立的裁定驳回异议
    - 当事人不服的，裁定10日内可向上级上诉
  - 原告撤诉，不再审查管辖权异议
  - 管辖权恒定：起诉时有管辖权，不会因为管辖因素的变化而丧失管辖
    - 除非原告主观为了卡级别管辖bug

- **四、证据**
  - 1、诉讼中需要证明的是待证事实，包括程序性的和实体性的
  - 2、免证的包括自然规律、定理及经验推定的、众所周知的事实，和已决文书和自认事实
  - 3、自认：对**不利自己**的事实加以陈述或承认
    - 免除对方证据责任+法官采信依据
    - 关键：自认的对象是法院和法官，包括文书中和口头
      - **有可能接受对方诉讼请求，但不承认事实**
    - **如一方对另一方陈述的事实，法官充分说明并询问后，仍不反对的，默示自认**
    - 共同诉讼：
      - 普通诉讼中，自认对自己有效
      - 必要共同诉讼中，都自认才有效

- **自认的限制**
  - 为达成**调解、和解进行的自认，不得在后续诉讼中作为不利证据**，除非当事人都同意或法律另有规定
  - 法院发现串通自认作假的，**与查明事实不符的自认不成立**
  - 身份关系（父可敌国）、国家社会利益事实、程序事项（自认管辖）不能自认
- 4、证明责任=主观证明责任+客观证明责任
  - 主观证明责任：谁主张谁举证，没举证直接败诉
  - 法官基于原告提交的证据形式，形成了临时心证
  - **客观证明责任：**
    - 被告基于原告主张，如果自认或不反驳，法官转为最终心证，被告败诉
    - 如被告主张但不举证，同上
    - **如被告主张了也举证了，此时案件陷入真伪不明状态，立法规定谁负担证明责任谁就承担败诉风险，此时为客观证明责任**
      - **客观证明责任的分配：谁主张的是积极事实，谁负担败诉风险**
      - ex. 张三主张借钱给李四，李四主张没借，双方举证后真伪不明，此时积极事实张三主张，张三败诉
      - ex. 张三李四借款事实无争议，李四主张还钱了，张三主张没还，双方举证后真伪不明，此时积极事实李四主张，李四败诉
      - ex. 张三李四借钱且没还钱无争议，李四主张诉讼时效已过，张三主张没过，真伪不明，此时积极事实李四主张，李四败诉
      - ex. 一般侵权案件过错责任，张三主张李四有侵权行为、结果、因果、过错，李四主张都没有，张三负担4个证明责任，任一真伪不明判张三败诉
      - ex. 无过错责任案件，张三主张李四3侵权要件，任一不明同样败诉
      - ex. 如果李四对侵权事实自认，但主张有减责免责事由，如不可抗力、意外事件、正当防卫、紧急避险、对方也有过失，若真伪不明李四败诉
    - **共同侵权（过错责任）：原告证明有加害行为、结果和过错，但无法查明是谁干的，此时共同被告要自证免责（切断因果），否则承担共同侵权责任**
    - **环境污染（无过错责任）：原告证明有加害行为、结果，被告要自证免责（切断因果），原告提的是反证、被告是本证**
- 5、民诉孤证（1个直接证据）能定案，刑诉不行
- 6、证据的**分类**
  - 按证明独立性：直接证据、间接证据（拼图碎片）
  - 按证据来源：原始证据（合同原件）、传来证据（晚于案件产生，签章后的复印件）
  - **按证明责任：本证（有证明责任、败诉风险的人提供的证据）、反证（推翻本证证据的证据）**
    - 先找待证事实是什么，比如有没有借款的问题，原告提出的借条是本证，被告提出的还款收条是反证

        - 此时待证事实转换为还款问题，收条成为本证，村口大爷为原告提供的证人证言、证明收条伪造是反证
    - **ex. 张三主张李四欠钱不还且提供了借条，李四主张张三也向其借过钱并提供了借条，由于李四提供的证据不属于待证事实范围，因此既不是本证也不是反证**
    - **ex. 张三主张李四欠钱不还并提供了转账记录，李四提出记录是手机购买款并提供了证据，此时的待证事实是转账是否为借款，李四证据能够证明不是借款，因此是反证**
    - **ex. 张三主张李四排污污染了自己养的鱼，并提交了前后鱼状态及排污证据，李四要自证因果免责，此时张三先提出的其实是反证，李四要提的是本证**
- 7、证据要真实、关联性、合法性
    - 非法排除：严重侵害人合法权益、违反法律禁止性规定、严重违背公序良俗
    - 民诉中陷阱取证合法，欺诈取证不合法
    - 刑诉中犯意诱导取证、逼供不合法，但欺诈、欺骗合法（审讯技巧）
    - 品德（格）证据
- 8、证据的**种类**
    - 书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人陈述、鉴定意见、勘验笔录
        - **鉴定意见、勘验笔录**
            - 鉴定意见：要有专业资质，如法医、物证专家等
                - 单方申请、双方选人，法院委托，有问题需回避
                - 费用当事人向法院预交，法院转给第三人，鉴定人要签保证书
                    - 故意虚假鉴定退钱，根据 情节罚款、拘留，犯罪追刑责
                - 对书面鉴定意见异议，一般解释说明，谁非要申请鉴定人出庭谁预交出庭费，败诉方承担
                - 自己找的是专家辅助人，可以对鉴定意见帮助质证，**辅助人不需要回避**、视为当事人陈述
            - 勘验笔录：审判人员和小弟来写（交警现场写的是交通责任认定书，是公文书证）
        - **证人证言**
            - **证人讲的是事实，不能发表意见，证人不需要回避**
            - 证人对年龄、智力、身体状况没有过高要求
            - 证人有利害关系、未成年，证明力低，不一定能反映客观真相，不能单独作为定案依据
            - 证人必须出庭佐证证言，除非因健康原因、客观原因或双方同意（无争议）可不来
                - 证人要签保证书，不敢签保证书自己掏钱，小孩可不用
            - 证人费用申请方垫付、败诉方承担
        - **当事人陈述**

        - **当事人陈述不得单独作为定案依据**
        - 当事人也要签保证书
      - **电子数据、视听资料**
        - 电子数据=刻光盘
        - 不禁止公共场合（不侵犯他人隐私权）的偷拍偷录
        - **有疑点、剪辑、p图的，不能单独作为定案证据**
      - **书证、物证**
        - 公文书证：带章的，一般推定为真实，但有相反证据足以推翻的除外
        - 私文书证
        - 物证
    - 总结
      - **推定真实：一般公文书证**
      - **证明力低的：有疑点视听资料，当事人陈述，有利害关系、不匹配的未成年证人证言，无法与原件原物核对的复印件**
      - **不能用的：非法证据，无正当理由不出庭的证人证言、鉴定意见**
  - 9、证据提出命令
    - 书证、物证、视听资料在对方当事人手中，负证明责任的当事人可以要求法院责令对方提交，申请费由申请人负担
      - ex. 医患纠纷里的病历
    - **对方拒不提交的，法院推定证据内容为真**
    - **对方妨碍、毁坏证据的，法院认定证据证明的事实为真，并可对行为人罚款、拘留**
  - 10、最佳证据规则：原件原物最佳，原则上应提交原件原物
    - **无法与原件原物核对的复印件证明力低**
- **五、诉讼保障制度**
  - 1、保全类型：财产、行为、证据保全
  - **2、诉前保全：起诉、执行前**
    - 启动：依申请，不保全会有损害
    - 管辖：被保全标的所在地、被申请人住所地、有管辖权法院（谁保全谁管辖）
    - **担保：必须要求提供担保**
      - **财产保全必须要，证据保全会造成损失的才需要担保**
    - 决定：48 小时内裁定
    - 解除：30 日内不起诉或仲裁
  - **3、诉中保全**
    - 启动：依申请、依职权，灭失、难得或有损害
    - 管辖：审理法院

    - 担保：可以要求提供担保
    - 决定：情况紧急，才48 小时内裁定
        - 不急的5天内
- **4、执行前保全：文书生效后、执行前**
    - 启动：依申请，必须紧急
    - 担保：无需
    - 管辖：**执行法院，仅财产保全**
- 5、保全的范围：
    - 限于诉请求范围，案外人财产不行
    - 可以保全次债务人对债务人的到期债权，可由法院提存财物或价款
    - 抵押物、留置物也可以设立，担保物权人优先受偿后可以喝口汤
- 6、保全的救济和解除
    - 救济：向保全法院申请复议，复议期间不停止保全
        - 保全错误的，找受诉法院（诉前的没有）和保全法院起诉要求赔偿
    - 解除原因
        - 保全错误，撤回保全，财产保全变更保全对象
        - 起诉、讼请被驳回
        - 诉前保全后30日内未起诉、执行履行期满没申请执行
- **7、先予执行：四费一金、劳动报酬**
    - 情形：
        - 诉中依申请，可要求担保
        - 因生活急迫、被执行人有钱，权利义务关系明确
    - 范围：
        - 扶抚赡、医疗费、抚恤金、血汗钱
    - 救济：申请复议，复议期不停执行
- **8、强制措施**
    - 训诫，责令退出、强制带离法庭
        - 故意违反法庭规则
    - **拘传：抚扶赡离婚案，被告不到要拘传**
        - 不来查不清情况
        - **程序：2次传票，无正当理由不来（延期），找院长开拘传票，逮过来开庭再放了**
    - 罚款、拘留：院长批准**决定书**，可向**上级**复议1次，使用决定
- 9、期间和补救
    - 期间计算方式：次日、次时
        - 最后一日是法定休假日（周六日不算）的，看节后第一日

- 期间不包括在途时间，交邮即可
  - ex. 9月16日送达判决书，17日开始算15天，最后一天是10月1日，至10月8日寄出上诉状即可
- 补救方法：因不可抗原因或其他正当理由耽误的，可在障碍消除后10日内，向法院申请顺延、由法院决定
- 特殊：
  - **在中国领域内没有住所的当事人，答辩期和上诉期增加一倍、为30日，还可申请顺延**
  - **涉外民诉没有审限**

- 10、送达
  - 直接送达：给本人或三代一家属（公司法代、当事人代理人、代收人，同住的成年家属）
    - 当事人来法院领，看完后不签回执，视为已送达
  - 留置送达：找一个见证人（或拍照录像）签字、留下法律文书
  - 电子送达：得当事人同意+确认当事人收到
  - 转交送达（行动受限的，不允许扩大）
  - 委托送达（委托外地法院送）
  - 邮寄送达（ems）
  - 公告送达（拟制送达，优先用其他）：受送达人下落不明，或无法用其他方式送达的，发出公告经30日（涉外60日）视为送达

- **六、调解与和解**
  - 1、调解的程序：
    - 遵循自愿、合法原则，原则上不公开
    - 人身关系确认之诉不得调解
    - 非诉程序、特别程序没有调解
  - 2、调解担保：
    - 与担保人签担保协议
    - 担保人无需签调解书
    - 调解协议的内容可以超出原诉请求，法院制作调解书
      - **可以不制作调解书的（没什么好执行的）例外：调解协议记入笔录，当事人、审判员、书记员签名盖章生效**
        - 离婚和好、维持收养关系
        - 即时履行
    - 签收调解书生效，不签收及时判决
    - 凭调解书直接执行债务人、担保人的财产
  - 3、私下和解
    - **和解没有时间限制，任何阶段都可以和解**

        - **和解协议在任何时候都不能作为结案依据、没有强制执行力，诉讼中的和解协议没有合同效力、更不能依据直接强制执行**
        - 和解了，可以撤诉，可以制作调解书、申请强制执行，也可能继续审理
- **B.分论**
- **七、一审普通程序**
    - 1、起诉的条件
        - **原告**是与本案有直接利害关系的人，是**当事人适格**/正当当事人
            - 有当事人能力不一定当事人适格，当事人适格一定有当事人能力
            - 有民诉救济的必要性与实效性
        - **有些没有直接利害关系的**人，也可以以适格当事人身份参加诉讼，如：
            - 失踪人的财产代管人
            - 著作权集体管理组织
            - 保护死者利益的近亲属
            - 公益诉讼的原告
        - **被告要明确**，不要求正确（不正确受理后驳回诉讼请求）
            - 明确=姓名+正常地址=能锁定人，下落不明也算明确
        - **有具体的诉讼请求、事实、理由**
            - 要属于民诉的范围和管辖
            - 哪怕是没有法条明确规定的权利
        - 书面起诉，或口头起诉+笔录
    - 2、立案登记的程序规则
        - 先登记、收材料、出具书面凭证，并一次性告知补正材料
            - 材料齐全的**7日内决定是否立案**
            - 如果短时间判断不了是否符合起诉条件，先立案
        - 审查符合起诉条件的，发出**受理通知书**，立案受理
            - 受理后发现不应受理的，发出**驳回起诉裁定书**
            - 对内叫立案、对外叫受理
        - 不符合条件的不受理，发出**不予受理裁定书**
            - **重复、判过的不受理**：当事人相同/相反+诉讼标的相同+诉情相同/否定
                - ex. 可乐爆炸，先诉请违约，再诉请产品侵权，不可以
                - ex. 诉请2万块债权中的1万，再诉请1万，法院认为已放弃另1万的残部请求，不可以
                - ex. 被撞了，先诉请医疗费，再诉请精神损害赔偿、护理费、误工费，可以
                - ex. 先诉请本金，再要利息，本金请求权和利息请求权是2个请求权，可以
            - **应予受理的案件：裁判后又有新情况、或超时效又起诉的（不得主动释明、援引抗**

辩，2审）
    - 一定期限不能诉：判不离、调解和好、撤诉，判维持收养关系，**没新情况新理由同一方**6个月内又来；女方怀孕、分娩1年内，终止妊娠6月内
  - 当事人对上述2个裁定不服的，可在**10日内向上级法院上诉**
- 3、起诉的效果：
  - 诉讼时效中断
  - 普通审限：6+6，+6月要院长批，可以报上级法院批准再延长
- **4、民诉的决定**
  - **罚款、拘留、回避、延期审理，可口头**

	判　决	裁　定	决　定
解决问题	解决实体问题	主要解决程序问题 （个别涉及实体问题）	解决特殊问题 （罚款、拘留、回避、延期）
形　式	必须书面	可以书面、口头	可以书面、口头
执行力	具有给付性内容才具有强制执行力		

  - **裁定：**不予受理、驳回起诉、管辖权异议、保全、先予执行、诉讼中止，可口头
  - 判决：实体问题，必须书面因为要执行
- 5、答辩
  - **受理后起诉状副本5日内送被告，15日内书面答辩**
    - 可提管辖权异议
  - 答辩是种权利，可以诉讼策略不答辩
- **6、举证时限**
  - 普通程序≥15日，二审≥10日
  - 简易程序≤15日，小额诉讼程序≤7日
  - 具体举证期当事人可约定，最终都由法院拍板
  - **时间不够，可在届满前向法院书面申请延长**
  - 没交齐的原则上后边不给交了
- **7、逾期举证：有用就采纳、没用就排除，故意要处罚**
  - 对方无异议、有用，必须采纳
    - **只是作为证据用，不是直接作为定案依据，与最终采信有区别**
  - 有异议、有用，要求逾期人说理
    - 有道理，
    - 没道理，一般过错，训诫
    - 没道理，重大过错，训诫+罚款
      - 罚款很贵，罚自然人1个10万、法人1个100万
- 8、取证

- 当事人调查取证为主，人民法院调查取证为辅
- **依职权调取的：身份程公**
  - 身份公益案件如离婚、赡养等
  - 解决程序问题：中止诉讼、终结诉讼、追加当事人、回避等
  - 涉及国家利益、社会公益、他人权益保护
- **依申请调取的（不是非得同意）：当事人因客观原因调取不到的**
  - 证据由有关部门保存一般人无法查询的
  - 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的
  - 其他
  - 实践中可出具调查令自己去调

- 9、证据交换：确定争议焦点，排除无用证据，简单案可以不用
- **10、审理方式：**
  - **原则上3/5/7人组成合议庭，可以吸纳陪审员，基院+简单案可以1人审（独任）**
    - 院长参加必须当审判长，陪审员不能当审判长
    - 陪审员不参与法律问题表决，事实问题全参加表决
  - 书记员干两件事：宣读纪律、记笔记。核对当事人身份是审判长
- 11、质证
  - 当事人包括第三人，对证据发表自己的意见（真实、关联、合法，证明力大小等）
    - 法官没有质证权
  - **一般质证都是公开**
    - **涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的不公开（质证但不旁听）**
  - 未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据
- 12、主动撤诉
  - 辩论终结前，法院同意可撤诉
  - 辩论终结后，胜负已分，除非法院+被告同意，否则不给撤
  - 撤诉后相当于没起诉，可就原纠纷再起诉
- 13、被动撤诉
  - **主体：原告及其法定代理人、有独三**
  - 情形：经传唤（1次）不来、擅自退庭、不交费，按撤诉处理
- 14、缺席判决
  - **主体：被告及其法定代理人（含反诉）、无独三、申请撤诉但法院不同意的原告（重婚）**
  - 情形：经传唤（1次）不来、擅自退庭，按缺席判决
- **15、延期审理**
  - **适用所有人，必须来的有正当理由没来，临时提回避，当庭拿出新证据，其他**

- 延期可以预计、中止不能预计，延期其他程序不停、中止所有都停
- **16、诉讼中止**
  - **（当事人）疯傻死，难抗拒，交叉案，要中止**
    - 行为能力丧失尚未确定代理人，自然人法人没了继承人没确定，一方因不可抗拒事由参加不了，本诉必须以其他诉结果为依据而未审结的，其他
      - ex. 故意杀人，刑事案先审，审完再民事
    - 中止的时间可能完全无法预计，中止情形消除后诉讼自动恢复
    - 注意没有证人
- **17、诉讼终结：都死绝、要终结**
  - 当事人嗝了没法争了，比如人死了、遗产没了、没后人了
- 18、在线诉讼
  - 不得采用：不同意、没条件、重大疑难、必须现场（核验）、国家秘密、国家安全、其他
  - 合理期限前可反悔
  - 简单案、都同意，允许异步审理
  - 在线不公开审判：国家秘密、个人隐私+国家安全
  - 在线申请不公开：离婚、商业秘密+未成年人
  - 可以电子送达
- **八、一审简易程序**
  - 1、基院+简单案，可以简易程序
    - 或首次开庭前，双方当事约定/同意，法院不反对的
  - 2、**不能用简易程序的**
    - **起诉时被告下落不明**（简易程序不得公告送达）
    - **第三人撤销之诉**
    - 重审、再审（说明是疑难复杂案件）
    - 代表人诉讼（人多）
    - 涉及国家、社会利益（重大利益）
  - 3、简易程序的特殊性
    - 普通程序：答辩、举证都≤15日
      - **简易程序：双方都到庭、都同意，不需要答辩期和举证期的，可以直接审理**
    - 送达：
      - **没有公告送达，可以简便送达**（比如打电话，不能放鸽子不然直接发传票）
    - 审理：
      - 全部独任审理，要配书记员
      - 必须开庭，可视频开庭，不受法庭调查、辩论的顺序限制，保障陈述权的基础上边查

边辩

- 审限：3+1，+1院长批
- **裁判文书：**
  - **当庭宣判，裁判文书和判决的事实和理由部分可以简化**
  - **结论部分、庭审笔录不能简化**

- 4、简易转普通程序
  - **首次开庭前，当事人异议、经法院裁定转**
  - **审限届满前，法院主动转（审不完了）**
  - **续审制**：简易程序走完的流程和审限不重来
- 5、小额诉讼程序（就是一种简易程序）
  - **简易+小额=必须用**
  - 简易/小额+约定=可以用
  - 不简易+不小额=不能用
  - 适用范围
    - 主要用于**金钱给付**案件
      - 其他金钱明确的简单人身损害赔偿案件、劳动合同纠纷、抚扶赡也可以
  - **不能用的：（贱）鉴人才涉诉，反、下落不明**
    - 要评估鉴定的或对结果有异议的
    - 人身关系、财产确权
    - 涉外案件
    - 当事人提出反诉的
    - 当事人下落不明的
  - **一审终审：**
    - **适用于其裁定（包括管辖权异议）、判决，原则上都不能上诉**
    - **但错误适用小额程序，导致剥夺当事人上诉权的**
      - **可以申请再审，再审判决是可以上诉的**
    - 特殊：海事法院是中院，小额海事案
  - 受理后当事人增加、变更诉讼请求、反诉、追加当事人，导致不符合小额条件的，可以转简易、普通程序
  - 审限：2+1
  - 裁判文书事实、理由部分可不写

- **九、二审程序**
  - **1、民诉仅上诉才能启动二审**
    - **刑诉才有抗诉启动二审**
  - **2、不能上诉的：督（嘴）最高特（工）公小调（皮）**

    - 督促、公示催告、特别程序非讼程序
    - 最高院一审的判决
    - 小额
    - 调解书
- **3、只有3种裁定可上诉：**
    - **不予受理、驳回起诉、管辖权异议**
- 4、上诉的主体
    - 原告、被告、法代、特别授权的委托代理人
    - 诉讼代表人
    - 有独三，被判决承担责任的无独三
- 5、上诉期
    - 判决15天，裁定10天
    - 境内没住所的30天
- **6、上诉形式：**
    - **必须书面（不同于起诉，没书面）**
    - 按时交书面上诉状=上诉成功
    - 上诉成功+不交钱=按撤诉处理
- **7、谁上诉谁就是上诉人，上诉的对谁不满就列为被上诉人，剩下的按原审地位列明**
    - ex. 甲乙二人打伤了丙，丙原告、甲乙共同被告，一审判完后
        - 丙不服要上诉，上诉人是丙，甲乙是被上诉人
        - 甲不服乙赔少了，上诉人是甲，被上诉人是乙，丙是原审原告
        - 甲不服丙要多了，上诉人是甲，被上诉人是丙，乙是原审共同被告
        - 甲乙丙都不服，上诉人是甲乙丙
- 8、二审上诉、起诉撤诉
    -

一审	二审	行为	结果
未生效	审理中	上诉撤诉+上诉期满	一审生效（不能再上诉，刑诉可以）
未生效	审理中	法院+当事人同意、撤回起诉	归零（无法再起诉）
判决错误	-	上诉+恶意串通、损害国社他利益	不准撤回上诉
刚受理	-	撤回起诉	可以再起诉

- 9、二审审理方式

- 原则上应组成合议庭，无陪审员
  - **例外：仅中院+一审简单案（一审简易程序或针对裁定上诉）+当事人同意=独任制**
- 原则上应开庭审理
  - **例外：程序、适用法律问题错误，没有证据事实问题**
    - 不予受理、驳回起诉、管辖权异议裁定程序
    - 原判决、裁定认定事实清楚，但适用法律错误的
    - 原判决严重违反法定程序，需要发回重审的
    - 上诉请求明显不能成立的（搓麻权）
  - 不开庭的审理方式：阅读案卷、询问当事人

- **10、审理范围：**
  - **不告不理（有其他错的没上诉不管）**
  - **有错必纠（除非涉及国社他的利益）**
  - **全面审理（针对上诉部分的事实、法律、程序全面复盘）**
- **11、二审具体裁判方式**
  -

情形	裁判
原裁定/判决认定事实清楚、适用法律正确	裁定/判决驳回上诉，维持原裁定/判决
原裁判/判决认定事实、适用法律有瑕疵，但裁判结果正确	纠正瑕疵，驳回上诉请求，维持原裁判
原裁定/判决认定事实、适用法律都错	裁定撤销或变更/依法改判
原裁判认定事实不清	裁定撤销原判、发回重审，或查清事实后改判
原判决严重违反法定程序（漏人漏判，组成、审判人员回避，违法缺席判，无法代、剥夺辩论权）	发回重审（漏人漏判先调，其他直接发）
违反专属管辖/不应受理	撤销原判，移送/驳回起诉

  - 正确要维持，瑕疵要纠正
  - 错误要改判，事实没查清、两种都可行，程序往回发
- 12、二审裁上诉、重审限制
  - **一个判决只能上诉一次**
  - **发回重审只能有一次**
    - ex. 一审ABC法官组成合议庭，审完得到甲判决，上诉发现严重违反法定程序，于是撤销原判、发回重审

        - ABC三个法官要全换，另行DEF组成合议庭，审完后得到乙判决，针对乙判决可以再上诉
        - 原二审法官没错可以继续审，但是不能再发回重审了，只能改判
    - 即便二审推翻一审，一审的举证、保全等行为在二审中也仍然有效；当事人的诉讼行为仍然有拘束力，推翻要说明理由、无理由不予支持
- 13、合议庭中按少数服从多数决策，形成不了多数意见要上审委会
    - 不同意见如实记入笔录，不同意见人必须签名
- 14、做出来的判决泼出去的水（既判力），有错别字可以作勘误裁定
    - 当庭履行的案件，经当事人同意可不出具裁判文书，在法庭笔录记录
- 15、二审的调解
    - 漏人、漏判：
        - **先调解，调解不成撤销原判、发回重审（接受调解=放弃上诉权）**
    - 特殊离婚案：
        - **一审判不离（子女财产没判）、二审判离（子女财产只判一次），这时应调解，调解不成全案发回重审**
    - 二审达成调解协议：
        - **调解书送达签收生效，一审判决视为（自动）撤销**
    - 二审达成和解协议：
        - **上诉人撤的是上诉，原审人撤的是起诉**
        - 也可以根据和解协议制作调解书，送达签收生效、一审自动撤销

- **十、审判监督程序**
    - 1、依职权：多是申诉（信访）程序导致
        - 本院院长提交审委会启动、上级发现错了提审
            - 漏人会侵犯案外第三人利益得主动管，追进来调、调不成发回重审
            - 漏判没上诉视为处分了、不告不理，不可以据此启动再审
        - **一个法院，只能再审一次**
    - **2、依申请**
        - **判决**
            - 证据有问题（少漏假、证明力、没质证等）
            - 法律适用有问题
            - 组织有问题（漏人、缺席、回避、辩论权等）
            - 裁判有问题（超判、漏判、司法职务犯、撤销变更原依据等）
                - 申请时间：裁判、调解书生效后6个月内（绝对不变期间）
                - **特殊4种：自知或应知6个月的6个月内**
                    - 新证据能推翻、定案证据伪造、司法职务犯、撤销变更原依据

- **调解书**
  - 违反自愿、合法原则
- 谁申请
  - 原审当事人，死亡、终止的权利义务承继者
  - 没追加的、案外的必要共同诉讼人
    - 一个人一个案件中，只能申请一次
- 3、申请的审查程序
  - 再审法院5日内受理、发出受理通知书
  - 应组成合议庭进行审查，审查期为3个月，院长批准可以延长，涉外无时限
    - 其他当事人提出再审申请的，审查期重新起算
    - 裁定再审的，应裁定中止执行，四费一金、血汗钱可以不中止
- **4、找谁申请**
  - 方式一：向上级申请
    - 提审：自己再审（二审程序）
    - 指令、指定再审：指令重新再审，指定原同级再审（原程序，另行组成）
      - **申请模式：不能指回基院审（意味着高院、最高院才能指）**
  - 方式二：向原审申请
    - 原法院、原程序、可基院
    - 适用：人多或双方均为公民，任一不满足得向上级
  - 方式三：检察院监督再审（抗诉）
    - 依申请：判决条件相同，调解书得自愿、合法原则侵害了国社他利益
    - 依职权
    - 上级抗下级，同级提建议
      - 再审法院收到抗诉书30天内裁定再审（准备好），不可以拒绝
    - 抗诉再审以提审为原则
      - 如果是证据问题，可以指令、指定下级再审**（可基层）**
      - 例外：已再审过的法院不得被指令再审（提审、指定）
    - 抗诉次数不限，检察院不是当事人，但应派人出庭支持抗诉
    - 检察建议：同级检察院对同级法院，内容不限于建议再审
      - 比如与裁判行为无关的违法行为
      - 还包括非诉程序的救济
      - 检察院可以自己去调查核实
  - 三种方法顺序：先找法后找检，法走不通2年内找检，检察院也只能找一次
- 十一、第三人撤销之诉
  - 1、条件：有独三、无独三+6个月内+侵害利益+裁判错+向错判法院

        - 不知诉讼而未参加/申请参加未获准/客观原因
        - 时限和再审一样，6个月的绝对不变期间
        - 不是有独三、无独三，绝对不能提第三人撤销之诉
            - eg. 甲诉乙本诉中，有独三丙提参加之诉诉甲乙，本诉中止，先审参加之诉。若本诉已判决，但古董是丙的、判错了
                - 丙只能提第三人撤销之诉撤销本诉，丙是原告，甲乙是被告
    - 2、三撤启动容易、效力弱，再审启动难、效力强
        - 原则上三撤无法中止执行，除非申请人提供善意的担保
            - 如果是恶意的担保，法院可以不准许中止
        - 担保不成立的，可以向**执行法院**提案外人异议来终止执行
    - 3、三撤属于变更诉，向错判的法院起诉
        - 可以请求撤销错误文书，也可以请求确认自己的权利
    - 4、哪里错误撤哪里，可更改为正确判决
        - 不允许撤的：
            - 非诉程序
            - 代表人公益诉讼判决
            - 婚姻案件涉及身份关系的内容（没必要）
- 十二、增加、变更诉讼请求和反诉
    - 1、增加、变更，等于放弃旧的、增加新的，反诉等于增加新的
    - 2、一审增变反，要在辩论终结前提出、合并审理
        - 否则先调，调解成功=放弃上诉机会
    - 3、二审增变反，先调（直接允许会剥夺上诉权，放弃上诉权可调可判）
        - 调不成告知另诉，另诉不能构成重复起诉，另诉不了直接判
    - 4、再审增变反，直接告知另诉（另诉构成重复起诉，则不告知）
        - 再审只解决旧错误
        - 如果是再审发回重审，原则上也不允许增变反，除非：
            - 原审漏人、缺席判导致剥夺辩护权，因为严重程序错误发回重审
            - 诉讼标的物灭失或发生变化，致使原诉讼请求无法实现，当事人只能提出新请求的
            - 当事人的增变反无法另诉的
    - 5、本诉与反诉应满足其一
        - 属于同一法律关系
        - 基于同一原因事实
        - 具有因果关系
    - 6、反诉应使用与本诉相同程序
        - 两个独立的诉，满足条件可合并审

- 7、反诉要求对本诉的法院也有管辖权
  - 本诉与反诉应有牵连关系（基于同一事实）
  - 除非反诉属于专属管辖，否则本诉当然取得反诉的管辖权
- 十三、公益诉讼程序
  - 1、类型
    - 环境污染、消费者权益、英烈姓名肖像名誉荣誉等
  - 2、原告特定——规定的机关和有关组织
    - 环境污染：5年公益无违法，依法在地级市以上民政部门登记的环保组织
    - 消费者权益：省以上的消协
    - 生态破坏、食品药品安全、特别影响民族感情的英烈利益：检察院
  - 3、检察院补充性
    - 可以支持起诉
    - 其他机关和组织不提才可以提
  - 4、起诉条件
    - 明确被告、具体诉请、管辖正确
    - 初步证据（一般侵权不要求这个）
      - 已发生、即将发生都行
  - 5、管辖
    - 侵权行为地、被告住所地的中级法院
    - 污染海洋环境归海事法院专属管辖，没有被告住所地
  - 6、审理组织：必须7人合议庭，4/3
    - 禁止反诉
    - 不同原告可以共同参诉、做共同原告，先立案法院先管
    - 可和解调解，文书公告 30 日
      - 公告期满，不违反社会公共利益的，制作调解书结案
      - 违反社会公共利益：审理并裁判
        - 法院可以主动调查证据
    - 公益诉讼原则上不允许撤诉
      - 不允许因达成和解协议而撤诉
        - 其他情况允许（如行政机关履行职责使原告诉讼请求实现）
      - 辩论终结后不允许原告撤诉
  - 7、可提私益诉讼，但不允许合并
    - 公益胜诉对私益诉可免证，但败诉不能免证
- 十四、特别程序
  - 1、特别程序7个，督、公2个

特别程序	选民资格案（确认选民资格）	宪法诉讼程序	作出判决
	宣告公民失踪、死亡案（确认是否失踪、死亡）	非讼程序	
	认定公民无、限制民事行为能力案（确认行为能力）		
	指定遗产管理人案（确定遗产管理人）		
	认定财产无主案（确认财产是否无主）		
	确认调解协议案（赋予人民调解协议强制执行力）		作出裁定
	实现担保物权案（拍卖、变卖担保财产）		
督促程序	督促债务人给付金钱或者有价证券		作出支付令
公示催告程序	解决票据和其他事项灭失等问题		作出除权判决

- 特别程序都是非民事诉讼程序（非讼+宪法诉讼程序）
- 共同特点
  - 管辖：基层法院
    - 例外：确认调解协议案，标的额超标的
  - 不适用调解，不适用辩论
  - 一审终审，不适用审判监督程序
  - 审判组织
    - 原则：独任制
    - 例外：审判员组成合议庭
      - 选民资格案
      - 实现担保物权案，标的额超标的
    - 开庭：都不开庭
      - 例外：选民资格案
  - 救济方法：提异议撤销流程，有异议直接撤销
- 2、选民资格案（宪法诉讼）
  - 必须先申诉，向选举委员会
  - 不申诉不得起诉
    - 起诉判定是否具有选举权，基院
    - 起诉人/有关公民
  - 要开庭，都法官的合议庭
- 3、宣告失踪、死亡案
  - 下落不明满2年，利害关系人申请
    - 在失踪人基院，公告3月
    - 判决宣告失踪，财产代管开始
    - 法院指定财产代管人
    - 代管人可单方放弃，请求重新指定

        - 有争议去起诉
    - 4年/意外事件2年/意外活不了没限制
        - 利害关系申请
        - 公告1年/意外活不了3月
        - 判决宣告死亡，继承开始
        - 户籍注销，财产继承，人身关系终止
        - 人回来了，提异议、法院撤销
            - 没法三撤、再审
- 4、认定无、限民事行为能力案
    - 利害关系人、有关组织，向被认定人住所地基院申请
    - 同时为其指定监护人，有争议去起诉
- 5、指定遗产管理人案
    - 有遗嘱、遗嘱执行人，遗嘱执行人为管理人
        - 可以是数人、法人、非继承人
    - 没执行人则继承人为管理人，继承人为多人要推选管理人
        - 不能推选非继承人
        - 没推选的，由全体继承人共担集产管理人
    - 管理人职责：清理、报告、保护、执行
    - 有争议，利害关系人申请指定
        - 死者住所地、主要遗产所在地法院
        - 法院依据有利于遗产管理的原则，判决指定
    - 客观事由可变更：管理人死亡、终止、丧失行为能力等情形
        - 主观干坏事的，可申请撤销
- 6、认定财产无主案
    - 财产所在地基院申请，法院公告1年寻找失主
    - 有人认领，无论是否真实，认定财产无主案终结，有争议去打确权诉
    - 没人认领，财产无主，收归国家、集体所有
        - 物主有异议去申请，撤销原判
- 7、确认调解协议案
    - 人民调解委员会主持下达成的调解协议
        - 合同性质、没有强制力
        - 发生争议可调可诉，调解没有次数限制，没达成调解协议可诉
        - 达成调解协议视为纠纷已解决，不能起诉原纠纷只能诉合同
    - **（唯一）双方申请司法确认，自调解协议生效30日内**
        - 法院组织的找法院，自己组织的找人、物、组织所在地基院

        - 纠纷中院级别**找中院**
        - 裁定有效/无效，是否自愿、合法，无效去诉原纠纷
    - **对身份确认、解除，物权确权、知识产权确权纠纷的调解协议不予确认**
- 8、实现担保物权案
    - 担保物权人或请求实现担保物权的人（抵押权人、留置人、质权人）
        - 要求拍卖、变卖财产以实现担保物权的案件
        - 向担保财产所在地、担保物权登记地基院申请
        - **原则上独任审查，但财产标的额超过基院管辖范围的，应当组成合议庭**
    - 当事人同意，裁定拍卖、变卖，依据裁定申请执行
        - 有争议、程序终结，去起诉
- 十五、督促程序
    - 1、支付令
        - 债权人向债务人住所地的基院申请
            - 法院形式审查，发出支付令
            - 债务人收到15日内可提异议
                - 不异议产生强制执行力
                - 异议程序终结
                    - 异议方式：没欠钱/直接在同法院起诉确认没欠钱
                - 异议可以撤回，撤回不能再提
        - 适用：
            - 金钱、有价证券（有数量、没质量）
            - 合法、确定、单向的
            - 债务人不能下落不明或在国外
                - 不能公告送达，可以留置送达
                - 30天送不到，程序终止
                - 送到谁手中，对谁有效
            - 债权人不能起诉或诉前保全
                - 针对债务人、担保人
    - 2、督促程序和诉讼相互转化
        - 没争议诉讼转督促
            - 要符合督促要求
        - 有争议督促转诉讼
            - 督促用的时间算作诉讼时间
            - 债权人可以决定不转
- 十六、公示催告程序

- 1、可背书转让的票据最后持有人
  - 票据被盗、遗失、灭失的情况下
  - 申请催告利害关系人在一定时间内申报权利
- 2、程序
  - 公示催告阶段——独任制
    - 票据支付地的基院申请（挂失）
    - 通知止付，票据冻结不得转让
    - 不少于60日公告期，申报权利（证明）
      - 没人报或被驳回——推定是申请人的
      - 有人来，程序终结
  - 除权判决阶段——合议庭
    - 1个月内申请，找同法院
    - 作出除权判决公告——不是判决，是票据（补办）
- 3、申报权利
  - 持票申报，申请人查验
    - 是，程序终结
    - 不是，申报失败
- 4、丢票权利人救济方式
  - 无票，错误除权判决1年内，向原法院起诉撤销除权判决
    - 起诉可举证
  - 有票，去申报

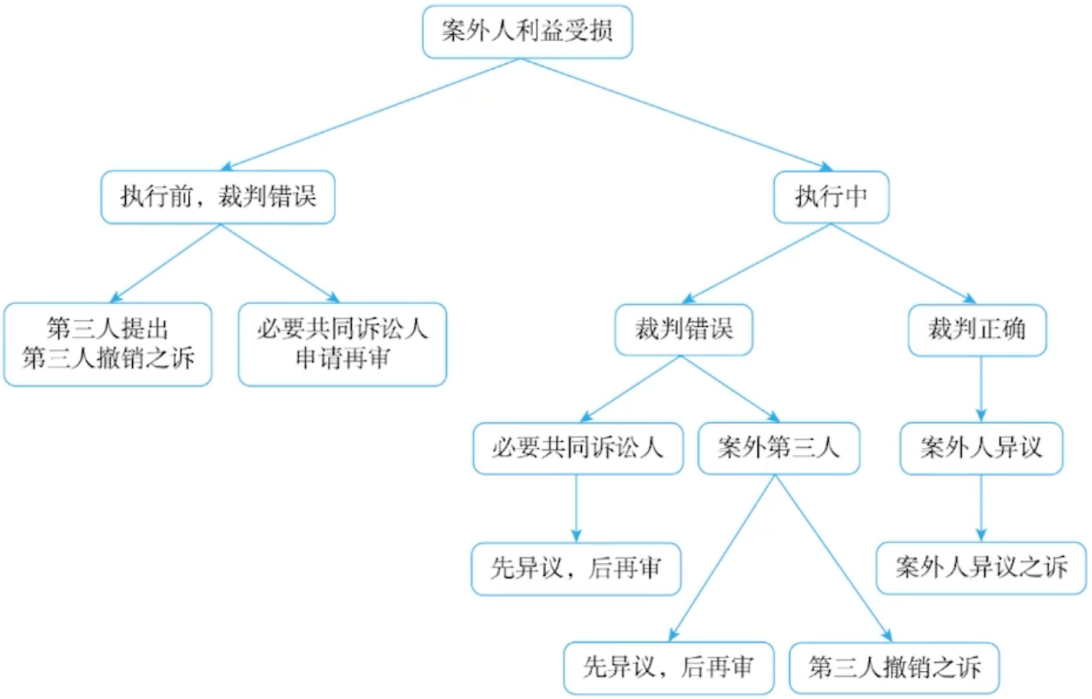
- **十七、民事执行程序**
  - **1、法院类的执行依据（法律文书）**
    - 民事文书：民事判决书、裁定书、调解书、支付令，民事制裁决定书（罚款）
      - 拘留不是民事执行局执行，是公安局
    - 行政文书：行政裁判、赔偿调解书
    - 刑事文书：刑事裁判中的财产部分，及刑附民判决书、裁定书、调解书
      - 罚没财产：罚金、没收财产
    - 法院承认的外国裁判、裁决的裁定书
      - 裁判和裁决直接拿过来不能执行
  - **2、其他机关的法律文书**
    - 行政处罚、处理决定书
    - 仲裁裁决书、调解书
    - 公证机关有强制执行力的债权文书
    - 其他

        - 结论：有民事诉讼不一定有执行，有执行也不一定是民事诉讼
- **3、管辖**
    - **离被执行人人身、财产最近的2个法院**
        - 法院文书：一审法院、被执行财产同级法院负责执行
        - 其他文书：被执行人住所地法院、被执行财产所在地法院负责执行
        - 支付令、确认调解协议案、实现担保物权案裁定：由作出法院、被执行财产同级法院负责执行
- 4、【执行】管辖权异议
    - 收到执行通知书之日起10日内
        - 异议成立，裁定撤销执行，告知当事人向有管辖权的法院申请执行
            - 区别诉讼，这里不自动移送，执行不让上诉
        - 异议不成立，裁定驳回
            - 救济：向上级法院申请复议
- 5、执行开始
    - 95%以上案件通过申请开始，其他依职权移送执行
    - **依职权：追三费，共（公）致（制）富（附）**
        - 给付抚扶赡，公益诉讼，民事制裁，刑附民
    - 依申请
        - **申请执行的期间：2年，可中止、中断**
            - 超过2年申请法院也应当受理
                - 债务人不异议则继续执行，异议则停
                - 过期还钱了，不能要回去
        - **未发现财产，可以终结本次执行**
            - 发现财产后再次申请、不受2年限制
- **6、被执行人的追加和变更**
    - 法人的分支机构、合伙企业的普通合伙人、执行中法人新设分立、公司认缴逾期实缴
        - 申请人申请、被执行人申请
    - 一人有限公司的股东
        - 不能证明公司财产独立于自己的财产的，人格否认
    - ~~注意新公司法征求意见稿是否生效~~
- 7、执行员接到申请执行书、移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可立即采取强制执行措施
- 8、执行阻却
    - 执行中不允许法院调解
    - 双方可自行和解，书面、口头都有效

- 不允许法院根据和解制作调解书、以物抵债裁定
- 书面协议/口头记录提交法院，没有强制力，可能改变执行内容
- 和解中断执行时效，和解协议到期开始重算2年
- 回家拿碗中止，申请人可主动终结
  - 不诚信拒绝履行，执行判决/起诉和解二选一，这里和解协议有合同效力（特殊）
  - 交付破碗，执行结案。可再起诉和解协议违约/以欺诈胁迫撤销和解、恢复执行
- 担保
  - 担保履行全部或部分义务，**经申请执行人同意**，向法院提交担保书
  - 暂缓执行期、担保期自愿约定，无约定担保期为1年
    - 暂缓结束担保开始
  - 转移、隐匿、损毁变卖债务人、担保财产，申请恢复强制执行
- 中止

执行依据	异议依据	法律效果	救　　济
确权裁判	确权裁判	不中止执行	案外人可以用再审、三撤撤销作为执行依据的确权裁判。
	给付裁判		
给付裁判	确权裁判	中止执行	债权人可以用再审、三撤撤销作为执行依据的确权裁判。
	给付裁判	不一定中止执行，要判断两裁判所认定的给付权利的优先性。	

  - 执行标的物归属不确定
  - 执行裁判效力不确定
  - 出现阻碍执行的客观情况
  - 其他
- 终结
  - 撤销执行申请，可再申请
  - 执行裁判被撤销
  - 被执行人死亡、无遗产、无继承人
  - 追索抚扶赡的人死亡
  - 被执行人没钱又无能，无法执行
  - 其他
- **9、案外人救济（侵害了利益）**



- **判决后、执行前**
  - 无需停执行，案外第三人提撤销之诉即可
- **执行后、原判对，先提执行异议**
  - 异议获支持，债权人诉案外人申请继续执行
  - 异议被驳回，案外人诉债权人（执行异议之诉），可要求中止执行或确认所有权
    - 驳回裁定15日内，向执行法院
- **执行后、原判错，先提执行异议**
  - 案外第三人：申请再审
    - 十一、第三人撤销之诉
  - 共同必要诉讼人：申请再审
    - 一审再审，追加案外人为当事人
    - 二审再审，先调、调不成发回重审+追加
  - 不同主体都提了，保留再审、追加案外人为当事人

- 11、执行行为的救济（未侵害案外人利益，执行多了、少了、过程错了）
  - 生活必需品、人格权密切相关的、人身上的，不能执行
    - 侵害了债务人利益：
      - 8人挤在50平房子里，可以变卖后收租金，或交赡养方
      - 应执行40万，结果执行48万
      - 应执行50万，结果执行48万
    - 侵害了第三人利益：侵害了租户优先购买权
      - 善意取得了不能异议了，只能诉房主侵害赔偿
  - **救济方式：先提执行异议、后向上级复议**

- 12、执行回转（判决撤了，执行返还）
  - 法院根据判决撤销出具返还裁定，执行依据是返还裁定
- 13、执行措施
  - 冻结、划拨：银行存款最多冻1年、其他3年，存款
  - 扣留、提取
  - 查封、扣押：查封、扣押动产做多2年，查封不动产最多3年
  - 拍卖、变卖：能拍卖就不变卖
  - 共有财产的查、扣、冻：
    - 通知共有人析产，无争议则分割
    - 分割不清，共有人诉债务人
    - 不愿分割，债权人代位析产诉，代位诉债务人
  - 自然人债务人的金钱债权分配：
    - 多债主、资不抵债
    - 按权利优先性、比例分配
    - 法院来分配，不适用法人债务人
    - 不服气向法院提异议
  - 对行为执行
    - 可替代行为的执行：转化为金钱债
    - 不可替代行为的执行：罚款、拘留、刑事责任（拒执罪）
- 14、保障执行措施
  - 搜：财产、会计帐簿等
  - 查：存款、债券、股票、基金等
  - 罚：支付迟延履行利息、罚金等
  - 财产报告：通知来法院报告财产去向
    - 拒绝或虚假：罚款、拘留
  - 声誉制裁等执行威慑：媒体公布，出境、征信记录
- **十八、商事仲裁**
  - 1、仲裁委员会：以仲裁协议为根基，约束协议双方，收受理费+处理费
  - 2、属于民间组织，解决财产纠纷，市级以上设立，协议任选哪家管，只能选一家
    - 通过名称、贸仲规则无法锁定的，视同仲裁协议没有约定仲裁机构
    - 可以选a仲裁委用b仲裁规则
  - **3、或审或裁，主从合同，从随主转**
    - 有仲裁约定，一方偷去法院起诉
      - 对方在首次开庭前异议，法院可裁定驳回起诉
      - 未在首次开庭前异议，继续审理

        - 无仲裁协议，仲裁应诉了同理
    - 在答辩期内应诉答辩，视为双方放弃仲裁协议
- 无仲裁约定，一方伪造去申请仲裁
    - 仲裁首次开庭前异议，异议驳回、仲裁裁决后申请撤销
    - 仲裁裁决后3月内，向仲裁机构所在中院申请撤销裁决
    - 可能构成虚假诉讼罪
- 如果仲裁协议效力本身存在争议，可申请法院或**仲裁委**先确定效力，原被告住所地、协议签订地、选的仲裁委所在地的中院，首次开庭前确定效力
    - 一方找法院、一方找仲裁确认效力，法院优先

- 4、不能解决的：
    - 人身纠纷、行政纠纷、劳动纠纷、土地纠纷
- 5、仲裁协议必须书面的：
    - 上诉状、管辖协议、仲裁协议、支付令协议、执行行为异议、执行标的异议、分与分配异议
- 6、独任仲裁：
    - 1个仲裁员，共同选或共同指定
- 7、仲裁庭：
    - 首席仲裁员+2个边裁
    - 边裁1人选1个，首席俩人或俩边裁一起选
        - 不会选可以委托主任指定
- 8、涉外海事案件的临时仲裁（略）
- 9、过程原则上不公开、不旁听
    - 当事人可共同约定不开庭、公开
- 10、回避
    - 原因：同诉讼
    - 决定：主任/除了主任一起投票
    - 回避后，区别与诉讼，仲裁庭可决定是重来还是继续
- 11、仲裁庭可自己收集证据
- 12、保全方式：同诉讼
    - 仲裁前，找法院申请保全措施
    - 仲裁中，仲裁委向法院提交当事人的保全申请，由法院采取保全措施
        - **国内证据、财产保全，找相关基院（正常情况下，涉仲裁中院管）**
        - 涉外证据、财产保全，找相关中院
- 12、仲裁结果
    - **依据调解协议做调解书**

        - 不能撤销、不予执行
    - **依据调解协议、和解协议做裁决书**
        - 可以撤销，不能不予执行
    - **普通仲裁做裁决书**
        - 可以撤销、不予执行
    - 仲裁协议只能用一次
        - 作出裁决书算用过（即便撤销）
        - 可诉，或达成新协议走仲裁
    - 依据和解协议撤回仲裁申请
        - 仲裁程序终结，不能恢复
        - 原仲裁协议没用过，可以再申请仲裁
- 13、裁决方式：
    - **少数服从多数**
    - **无多数意见听首席的**
        - **少数意见可不写入笔录、可签可不签（区别诉讼必须写必须签）**
    - **仲裁审错了责任豁免，除非违法**
    - 当事人虚假仲裁要判败
    - 有笔误可补正
- 14、一裁终局
    - 马上生效、不能起诉、不能再仲裁
    - 具备强制执行内容申请法院执行
- 15、裁决有毛病
    - **申请确认仲裁效力、申请撤销和不予执行仲裁裁决，是非讼程序，没纠纷**
        - 能申请撤销情形=不予执行情形：
            - 无仲裁约定、超裁、仲裁程序违规、伪造隐瞒证据（非新证据）、仲裁员被抓了
        - 任一被驳回再申请另一个，不支持
    - **或撤销或不予执行，都申请先看撤销**
        - 双方都可申请撤销，自收到裁决3月内
            - 找仲裁机构所在中院
        - 债务人、案外人可申请不予执行
            - 仅在执行启动后，才能申请
    - **重新仲裁：类似发回重审**
        - 法院在审理撤销仲裁程序中，发现仲裁是错的，先沟通仲裁委、中止撤销程序
            - 愿意重新仲裁，终结撤销程序、仲裁委作出新裁决
            - 不愿意，恢复撤销、撤销仲裁

- 16、仲裁与破产的竞合
  - 先受理破产再启动仲裁：债权人先申报债权，管理人预留分配额。破产程序终结日2年内必须完成仲裁，否则预留分其他人，仲裁债务不得大于分配额。
  - 先仲裁结束再受理破产：持仲裁结果直接申报债权；仲裁有误得先申请撤销仲裁
  - 仲裁与破产均刚启动：仲裁暂停，等管理人接管后继续。